PODERES ADMINISTRATIVOS II

A) PODER DISCIPLINAR

Em relação aos poderes administrativos, um dos mais importantes é o poder disciplinar. O poder disciplinar provém da ideia de disciplina. O poder disciplinar é o poder de punir os servidores pelas suas infrações funcionais. Um detalhe adicional é que a punição se estende também ao particular, quando este possui um vínculo especial com a Administração.

Portanto, quando o particular tiver algum vínculo especial e nesta relação especial praticar alguma infração, ele está sujeito ao poder disciplinar. É necessário cautela. O primeiro ponto é que, quando o servidor pratica uma infração funcional e sofre uma sanção prevista em seu estatuto, manifesta-se ali o poder disciplinar, que é a aplicação de punições para manter a disciplina interna.

Contudo, é fundamental ter atenção, pois, via de regra, quando o particular é punido, trata-se de poder de polícia. Entretanto, se este particular detém algum vínculo especial com a Administração e nesta relação especial sofre uma sanção disciplinar, configura-se também o poder disciplinar.

O caso mais comum envolve o particular que celebrou um contrato com a Administração para realizar uma obra pública. Naquele contrato existiam obrigações, e o particular descumpriu o pactuado. A Administração aplicou-lhe uma multa contratual, uma sanção de suspensão contratual ou uma sanção de advertência, em razão do descumprimento do contrato. O poder exercido foi o disciplinar, em função da relação especial existente.

Esta relação especial era o contrato firmado com o Poder Público. Foi este contrato que o diferenciou e o submeteu a um vínculo especial. Em concursos, pode-se encontrar a terminologia particular com “vínculo especial”, “sujeição especial” (que representam o mesmo conceito), ou “supremacia especial do Estado frente ao particular”, caracterizando o poder disciplinar. Há o caso do contratado que firmou contrato e se submete ao poder disciplinar.

Outro caso frequente em provas é o de aluno de escola ou faculdade pública que sofre sanção da universidade (advertência, suspensão, jubilação, expulsão); ali também se manifesta o poder disciplinar, devido à relação especial. Outro caso que ocorre em provas é o do preso que sofre sanção do diretor do presídio, como regressão de regime ou envio ao regime diferenciado, conforme previsto na Lei De Execução Penal; ali também está presente o poder disciplinar.

Trata-se do Estado em relação ao particular. O preso não é servidor, apesar de estar sujeito a uma supremacia do Estado, uma supremacia especial por estar preso e sob um regime diferenciado. Neste caso, ao sofrer sanção, o poder disciplinar é aplicável.

Se o particular for multado na rua, o poder é de polícia. Se o particular tem o carro apreendido ou a casa demolida, e há uma relação geral, um vínculo geral, supremacia geral, ou seja, o vínculo com a pessoa multada por colocar o carro irregular na rua é um vínculo geral (que qualquer pessoa tem com o Estado, que todos os indivíduos têm), o poder manifestado é o de polícia.

No entanto, se há um vínculo especial, sujeição especial ou supremacia especial, decorrente de alguma relação especial – como um contrato administrativo, um ato administrativo que faculta a prestação de um serviço, a situação do aluno de escola pública (que tem um vínculo diferenciado com a escola/universidade), ou do preso no presídio –, há sujeição especial, e a sanção é aplicada pelo poder disciplinar.

Este poder disciplinar possui como característica a discricionariedade. É um poder discricionário. Quando o Direito, em geral, conceitua algo como discricionário, significa a existência de liberdade de escolha.

5m

Logo, a caracterização de um poder como discricionário significa a existência de certa margem de liberdade para escolhas. O primeiro ponto a ser mencionado em relação à discricionariedade é a chamada atipicidade das infrações administrativas.

Esta atipicidade difere do que ocorre no Direito Penal. No Direito Penal, vigora o princípio da tipicidade penal: todo fato que é crime possui definição prévia e precisa na lei. Os crimes que podem ser cometidos estão integralmente previstos em lei (tipicamente), o que caracteriza a tipicidade penal. No Direito Administrativo, por outro lado, há a atipicidade das infrações, pois nem todas as infrações estarão necessariamente previstas em lei.

O que se tem na lei administrativa são muitos comandos gerais e abertos, denominados conceitos jurídicos abertos ou conceitos jurídicos indeterminados, onde se pode enquadrar o fato. No exemplo em que a lei estabelece que quem pratica conduta escandalosa na repartição está sujeito à demissão. A lei não define exatamente o que é essa conduta, mas deixa o conceito aberto.

Portanto, quando alguém pratica uma conduta, e é instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), a comissão decide que a conduta foi escandalosa. Assim, o fato é enquadrado como conduta escandalosa, e o servidor fica sujeito à demissão.

A lei estabelece, por exemplo, que quem pratica insubordinação grave em serviço está sujeito à demissão. Contudo, ser insubordinado é um conceito aberto. Pode-se incluir aquele que se atrasa diariamente e não cumpre ordens, ou aquele que não cumpre ordem legal do chefe. É possível enquadrar diversas situações como insubordinação grave em serviço.

O mesmo raciocínio se aplica ao ato de incontinência pública. A lei estabelece que quem comete incontinência pública, ou seja, a falta de controle sobre impulsos sexuais, pode ser demitido. Existem várias condutas cotidianas que, dependendo da situação, podem ser enquadradas como incontinência pública. Há registro de um processo de servidor que

se masturbava no trabalho. A conduta foi enquadrada como incontinência, resultando em demissão.

Outra situação: quem pratica desídia no serviço público. Desídia significa atuar com desleixo, descaso ou fazer algo "de qualquer jeito". A lei não conceitua todos os casos de desídia. É preciso analisar o fato para verificar se ele se encaixa no conceito.

Esta é a chamada atipicidade das infrações administrativas. Reiterando: nem toda infração estará totalmente definida em lei. Há muitos conceitos jurídicos abertos e conceitos jurídicos indeterminados, que possibilitam o enquadramento da infração e a aplicação da sanção respectiva. Esta atipicidade da infração confere ao poder a natureza discricionária.

10m

A discricionariedade manifesta-se também na escolha da sanção a ser aplicada. Em muitos casos, a lei concede esta liberdade. Não apenas na escolha da sanção, mas também na escolha do enquadramento do fato infracional. Para exemplificar a escolha de sanção: se o servidor pratica um ato com falta de moralidade, sendo dever atuar com moralidade, e a lei estabelece que, se for uma simples falta de moralidade (infração leve), a sanção pode ser advertência ou suspensão por até 30 dias. Esta margem de liberdade permite optar por uma advertência ou por uma suspensão. Na suspensão de até 30 dias, há 30 opções, pois a aplicação pode ser de 1 a 30 dias.

Existe, portanto, liberdade para escolher a sanção, bem como liberdade para decidir o enquadramento. A comissão e a autoridade julgadora analisam o fato para decidir onde ele será enquadrado, pois a sanção depende do enquadramento (advertência, suspensão ou demissão).

Já houve caso de servidor que apresentou atestado falsificado para abonar faltas. O órgão tomou conhecimento e instaurou o processo disciplinar. A comissão avaliou se a conduta violou a moralidade ou se atingiu o extremo de cometer ato de improbidade. A comissão tem a discricionariedade de avaliar. Teve caso em que a comissão entendeu que a apresentação de apenas um atestado falsificado violou o dever de moralidade, aplicando uma suspensão de 15 dias.

Em outro caso, um servidor, para evitar ser demitido por abandono de serviço, marcou consulta, subtraiu um talão de atestados do médico e apresentou mais de 30 atestados falsificados. A comissão descobriu e, diante da gravidade (tentativa de evitar abandono de cargo e a quantidade de atestados), enquadrou como improbidade.

Pode haver, por exemplo, um médico que não segue o procedimento padrão ao atender pacientes (uso de jaleco branco, luvas, máscara etc.). Ao ser denunciado, a comissão pode entender que se trata de uma infração por não cumprir normas administrativas (infração leve), aplicando advertência ou suspensão. Contudo, a comissão pode entender que o ato configura insubordinação grave, enquadrando a conduta como insubordinação, o que gerará demissão.

15m

É a liberdade de analisar o fato e decidir o melhor enquadramento. Isto é discricionariedade. Se a regra geral for questionada, o poder disciplinar é discricionário.

No entanto, deve-se registrar uma observação de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o poder disciplinar é vinculado.

O STJ reconhece que o poder disciplinar é discricionário em diversos julgados. No entanto, há julgados que analisam, muitas vezes, o seguinte caso: o servidor praticou uma infração cuja punição está prevista em lei, mas a comissão aplicou outra. Por exemplo, o servidor praticou abandono de cargo (ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos).

Foi configurada a intenção de abandonar o cargo, com mais de 30 dias consecutivos de faltas. A comissão instaurou o processo e aplicou apenas suspensão. O STJ entende que, neste caso, o poder disciplinar é vinculado. Se foi configurado o abandono de cargo e a lei prevê demissão, a demissão deve ser aplicada.

Outro caso é a notícia de infração praticada pelo servidor, a abertura do processo, a reunião de provas, e o servidor não é punido no final. O STJ afirma: o poder disciplinar é vinculado. O processo ocorreu, há provas, e o servidor deve ser punido; nesse caso, a punição não é discricionária, mas vinculada à conduta.

A primeira resposta para a prova é que o poder disciplinar é discricionário. Contudo, se for perguntado se, na visão do STJ, o poder disciplinar é discricionário, deve-se marcar que não, pois ele é vinculado, em função de diversos julgados que seguem a direção explicada e que afirmam expressamente que o poder disciplinar é vinculado. O examinador pode retirar este trecho de um julgado do STJ e inseri-lo na prova, devendo-se marcar o entendimento, nesse caso, de acordo com o STJ.

Será abordada em breve a Súmula n. 650 do STJ, que estabelece que a autoridade administrativa não tem discricionariedade para aplicar pena diversa da demissão quando enquadrar o fato em uma das situações do art. 132 da Lei n. 8.112. O art. 132 da Lei n. 8.112 lista todas as infrações que geram demissão (improbidade, condutas escandalosas, incontinência, desídia, crime, aplicação irregular de verba pública, acumulação ilegal de cargo, exercício de gerência de empresa privada, inacessibilidade habitual, entre outras situações).

A Súmula n. 650 do STJ reflete um entendimento consolidado: a comissão tem liberdade para analisar o fato e enquadrá-lo. Contudo, se o servidor praticou uma conduta, esta é enquadrada como ato de improbidade do art. 132 da Lei n. 8.112 e a lei prevê que, nestas situações, a sanção é a demissão, nesse caso a demissão precisa ser aplicada.

Não se pode afirmar que o ato de apresentar atestado falsificado foi improbidade, mas que será aplicada uma suspensão. Não há margem de discricionariedade para enquadrar o fato em infração do art. 132 e aplicar sanção menos gravosa. Neste aspecto, o poder disciplinar não é discricionário.

Portanto, o poder disciplinar é um poder de punir servidores e particulares que possuem vínculo especial. Ele é discricionário, como regra geral, nos pontos mencionados, mas, na visão do STJ, nestes aspectos, ele também é um poder vinculado.

DIRETO DO CONCURSO

20m

01. (CEBRASPE-CESPE/PGE-PI/PROCURADOR/2025) No âmbito de um processo administrativo disciplinar, a aplicação de sanção pela autoridade competente a servidor público que tenha praticado ilícito administrativo exemplifica a manifestação do poder disciplinar

02. (FCC/CGM-SP/AUDITOR DE CONTROLE INTERNO/ÁREA: GERAL CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/2025) Considere que determinada empresa tenha sofrido sanção de inidoneidade em função de descumprimentos reiterados em contrato de concessão celebrado com a Administração Pública municipal. A aplicação da referida penalidade à contratada representa o exercício pela Administração de poder

a) extroverso, eis que independe do vínculo contratual estabelecido entre as partes e deriva de previsão legal.

b) regulamentar, derivado do poder de polícia, este que autoriza a imposição de restrições e sanções.

c) hierárquico, decorrente da supremacia do interesse público sobre o particular e com vistas a preservar a continuidade do serviço público.

d) disciplinar, presente quando há vínculo jurídico entre o particular e a Administração.

e) normativo, presente nas denominadas cláusulas exorbitantes do contrato administrativo.

a) O poder extroverso não é um poder administrativo. É o poder do Estado de exercer supremacia sobre o particular e, neste sentido, aplicar sanções e impor restrições. O Estado detém um poder extroverso sobre o particular, que é a capacidade de interferir na sua vida, impondo condutas, abstenções de atos e punições. É um poder extroverso por inerência à vida no Estado. Ele não é um poder administrativo. O poder administrativo está nas mãos do gestor (poder de polícia, poder regulamentar, poder disciplinar, poder hierárquico etc.). O poder extroverso é o poder estatal de interferir na vida do particular, impondo restrição, sanção ou abstenção de atos em benefício da coletividade. O poder de polícia decorre diretamente do poder extroverso; contudo, o poder extroverso não é um poder administrativo, mas um poder estatal, mais abrangente que os poderes administrativos.

b) Poder de fazer decretos para complementar lei.

c) Poder de estabelecer hierarquia interna.

d) O poder disciplinar se manifesta quando há vínculo jurídico específico entre o particular e a Administração.

e) Poder de fazer atos normativos complementando lei anterior.

GABARITO

01. C

02. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Gustavo Scatolino.
A presente degravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.